

Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC

PREVARICATO POR ACCIÓN – Elementos Estructurales.

En este orden de ideas, se llamó a responder al procesado por realizar objetivamente la descripción típica consagrada en el artículo 413 del Código Penal (Ley 599 de 2000), definida como el punible de prevaricato por acción.

Para efectos de dimensionar en qué consiste la realización objetiva del tipo penal de prevaricato, como complemento de la falta disciplinaria que motivó esta actuación, veamos si aparecen cumplidos los elementos estructurales del punible en cuestión.

La descripción penal empieza por exigir un sujeto activo cualificado, referido a un servidor público con capacidad funcional de proferir, cualquiera de los tres actos que conforman el objeto material del ilícito, - resolución dictamen o concepto -.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 48 NUMERAL 1 / LEY 599 DE 2000 ARTICULO 413.

PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN SUBJETIVA / FALTA DISCIPLINARIA A TITULO DE DOLO

El principio general de imputación subjetiva en materia disciplinaria señala que *“En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa”* (Artículo 13, ley 734 de 2002).

Acudiendo dentro del marco autorizado de integración normativa por el artículo 21 del Código Disciplinario Único, al artículo 22 del Código Penal define que la conducta es dolosa cuando *“... el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. ...”*

Con relación al dolo ha sostenido reiteradamente la doctrina disciplinaria: *“...Entonces, para que exista dolo basta que la persona haya tenido conocimiento de la situación típica aprehendida en el deber que sustancialmente se ha infringido, y haya aceptado que le corresponde actuar conforme al deber. El conocer ya involucra al querer, pues si conozco y realizo la conducta es porque quiero, lo cual ha sido pregonado por HRUSCHKA al sentenciar que “quien sabe lo que hace y lo hace, quiere hacerlo...”* (Dogmática del Derecho Disciplinario, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, edición 2ª, pag. 340) ...”

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 13 - 21

Dependencia:	Dirección General
Número del Proceso:	1704-01-2012-199
Número y fecha del fallo:	025 del dieciocho (18) de octubre de dos mil trece (2013)
Asunto:	Fallo de segunda instancia
Criterio de Selección:	Fallo de primera instancia confirmado en segunda instancia.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2012-199.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado (XXX), en su condición de defensor de confianza del procesado, (XXX), contra el fallo sancionatorio proferido por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, en la audiencia especial celebrada el 24 de junio de 2013.

COMPETENCIA

La suscrita Directora General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, es competente para resolver la presente impugnación, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 4173 de 2011, aclarado por el Decreto 4452 de 2011, en atención a las previsiones contenidas en los numerales 12 y 13 del artículo 3° del Decreto 00985 del 14 de mayo de 2012, y al contenido del artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES

1.- Los hechos que originaron la presente actuación, fueron informados por la servidora (XXX), en su condición de Jefe de división de gestión de recaudo y cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, mediante oficio 144242 del 25 de mayo de 2012, dirigido a la Directora Seccional de la DIAN en Yopal, (XXX), quien a su vez remitió los antecedentes documentales respectivos a esta entidad, a través de correo electrónico del 28 de mayo de 2012, direccionado por el sistema VIGÍA de la DIAN. Las funcionarias en mención, pusieron de presente el desembargo posiblemente irregular de las cuentas bancarias pertenecientes a la contribuyente (XXX), identificada con el Nit (XXX), ordenado mediante resolución N°201202.31000154 del 14 de mayo de 2012 y comunicado en la misma fecha al Banco Agrario. Según las servidoras informantes, tanto la resolución como el comunicado de desembargo aparecen suscritos por el funcionario (XXX), y la irregularidad de su actuación radicó, por un lado, en evidenciar que el expediente de cobro respectivo estaba asignado a otro servidor público, el funcionario (XXX) y no a él. De otra parte, se advirtió la existencia de obligaciones pendientes a cargo de la contribuyente, por valor de \$ 5'268.100, 00.

2.- Por los hechos aquí relatados, la Subdirección Técnica de Investigaciones Disciplinarias de la UAE Agencia ITRC, mediante auto datado el 18 de septiembre de 2012, dispuso la apertura de indagación preliminar contra el funcionario (XXX), quien se notificó personalmente de la decisión el 31 de octubre del mismo año. Ver fls. 9 a 13 y 96 del c. o.

3.- Habiéndose desarrollado la etapa de indagación preliminar, con la recopilación de pruebas testimoniales, documentales, técnicas periciales y de inspección, el despacho de conocimiento citó a audiencia al servidor implicado, mediante auto calendado el 8 de abril de 2013, llamándolo a responder por la falta gravísima contemplada en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, relacionada con la realización objetiva del tipo penal de prevaricato por acción, previsto en el artículo 413 del C. P. Esta decisión fue notificada personalmente al acusado el 11 de abril del mismo año.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2012-199.

4.- La audiencia pública tuvo su inicio el 29 de abril de 2013, con la presencia del procesado y su defensor de confianza. En desarrollo de la vista pública, el apoderado del procesado presentó descargos, solicitó la nulidad del proceso y requirió la práctica de pruebas testimoniales y periciales. El despacho de primera instancia negó las nulidades planteadas, accedió a la práctica de los testimonios y rechazó el dictamen pericial pretendido por la defensa. Ante la apelación del auto que decretó parcialmente las pruebas del juicio, este despacho de segunda instancia debió rechazar los argumentos del impugnante, confirmando el auto apelado, el 21 de mayo de 2013. El 27 del mismo mes y año fue notificado el defensor del acusado del auto de segundo grado, confirmatorio de la negativa de pruebas.

5.- El 16 de mayo de 2013 se reanudó la audiencia especial, con la recepción de las declaraciones juramentadas decretadas a petición de los sujetos procesales.

6.- Después de suspender el desarrollo procesal de la audiencia en dos oportunidades, a petición de los sujetos procesales, el funcionario a quo reanudó la vista pública el 24 de junio de 2013, oportunidad en la cual se escuchó en versión al investigado y se otorgó el uso de la palabra al procesado y a su defensor, respectivamente, para presentar alegatos de conclusión. Concluidas las intervenciones, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la UAE Agencia ITRC, profirió el fallo de primera instancia, a través del cual declaró la responsabilidad disciplinaria del acusado, sancionándolo con Destitución e Inhabilidad General de trece (13) años. El fallo de primer grado se notificó en estrados a los sujetos procesales y a petición del abogado defensor se concedió término hasta el 26 de junio del mismo año para impugnar la decisión de instancia. En la fecha acordada se recibió el escrito sustentatorio de la apelación, concediéndose la impugnación al día siguiente, para lo cual se remitieron y recibieron las diligencias el 27 de junio del año en curso.

7.- Con auto calendado el 5 de julio de esta anualidad, este despacho de segundo grado dio aplicación al inciso séptimo del artículo 180 del C. D. U., modificado por el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011. La decisión fue notificada por Estado desfijado el 29 de julio del año en curso, recibiendo nuevamente las diligencias el 31 de julio del mismo mes y año, para proferir el fallo de segunda instancia.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN IMPUGNADA

El operador disciplinario de primera instancia inició sus motivaciones, haciendo referencia a las disposiciones legales que le otorgan competencia para fallar el presente caso. Acto seguido, determinó que el servidor (XXX), identificado con la cédula de ciudadanía N°(XXX), fue vinculado al proceso, en su condición de gestor 1, nivel 301, grado 01, ubicado en la División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal. A continuación, resumió la situación fáctica y el desarrollo procesal del plenario.

Adentrándose ya en las consideraciones, realizó el a quo un análisis detallado de las pruebas documentales. Periciales, de inspección y testimoniales allegadas al proceso.

En un acápite subsiguiente, emitió el a quo un pronunciamiento sobre los argumentos defensivos esgrimidos a lo largo del proceso, por los sujetos procesales, de una parte el procesado en su versión, y, por otra, el defensor en el memorial de descargos y en las alegaciones finales o de conclusión.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2012-199.

Con base en este análisis, aseveró que el requisito de certeza en la existencia de la falta y en la demostración de responsabilidad del disciplinado, se cumplió dentro del caso sometido a estudio. Complementando su argumentación, afirmó el fallador de instancia que los elementos descriptivos del tipo penal de prevaricato por acción, se evidenciaron en el proceder del investigado, quien profirió la resolución y el comunicado ya mencionados, ordenando, en oposición a la normatividad legal, el levantamiento de una medida de embargo, que pesaba sobre las cuentas bancarias de la contribuyente, Gómez Salcedo, sujeto pasivo de un proceso de cobro coactivo. Simultáneamente con la motivación que permitió concluir y confirmar la estructuración de la falta disciplinaria objeto de acusación, el operador disciplinario de instancia encontró que los lineamientos jurisprudenciales referentes al punible de prevaricato por acción, tienen total aplicabilidad o presencia dentro del caso sometido a estudio.

De los conceptos de ilicitud sustancial y moralidad pública, consideró el a quo que la conducta del procesado fue trascendente y afectó la función pública, por desconocimiento de los postulados de honradez, transparencia, rectitud, eficacia y lealtad, que debía observar, como servidor público. Frente al análisis de culpabilidad, el fallador de instancia reiteró o ratificó los planteamientos realizados en el pliego de cargos, al considerar que las condiciones personales del procesado permiten denotar el conocimiento que tenía de la ilicitud del hecho, pese a lo cual su voluntad estuvo orientada a la realización de la conducta objeto de reproche, dolosamente. Frente a las manifestaciones defensivas esgrimidas por los sujetos procesales, el a quo manifestó enfáticamente que el proceder del acusado no fue justificado.

Considerando cumplidos los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial, culpabilidad y responsabilidad, frente a la estructuración de la falta, el fallador disciplinario de primer grado efectuó el juicio de dosificación de la sanción, aplicando en favor del procesado su carencia de antecedentes fiscales y disciplinarios; el hecho de no haber desempeñado un cargo jerárquico; su diligencia y eficiencia en el desempeño del cargo o función; no haber atribuido infundadamente responsabilidad a un tercero. Valoró negativamente el daño social causado, reflejado en la afectación de la confianza existente en los administrados frente a la función pública de la DIAN y sus agentes. Por lo anterior, concluyó que la sanción a imponer a la procesada no era otra que la Destitución e Inhabilidad General para ejercer funciones públicas por el término de trece años.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Dentro de la oportunidad procesal pertinente otorgada por el director de la audiencia, el defensor de confianza designado para el procesado presentó y sustentó su recurso de apelación con los siguientes planteamientos:

- A) Inició su argumentación el apelante, con un título denominado “FUNDAMENTO FÁCTICO”, en el cual hace una crítica al juicio de valoración probatoria realizado por el a quo, frente a cada una de las pruebas testimoniales de descargos, practicadas a solicitud de la defensa.

1.- Con relación al testimonio de la funcionaria (XXX), Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, expresó el apelante que no se valoraron o tuvieron en cuenta los siguientes hechos:

1.1.- Que según el dicho de la testigo, la contribuyente nunca afirmó conocer al procesado ni identificarlo como el asesor externo a quien pagó presuntamente la suma de un millón de pesos por obtener el levantamiento de la medida de embargo.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2012-199.

1.2.- Que el testimonio aludido, en ningún momento le atribuye responsabilidad o autoría al señor Pulido Chacón.

1.3.- Que el citado testimonio resulta parcializado pues pretende presentar al implicado como el “funcionario corrupto de la entidad”.

1.4.- Que la declaración en cita debió ser desvalorada, pues se evidencia en la testigo posible ineficiencia, frente al cumplimiento de sus deberes funcionales, pues al enterarse, por parte de la ciudadana Julia Mercedes Gómez Salcedo, de posibles irregularidades en que se estaban presentando en el levantamiento de las medidas de embargo, ha debido instarla a que formulada la queja disciplinaria o la denuncia penal, ante el funcionario competente.

1.5.- Que el citado testimonio denota la existencia de deficiencias, más o menos constantes, en el funcionamiento del sistema SIPAC, que generaban inseguridad en el trámite de embargos y desembargos, lo que a la postre obligó a la administración a tomar medidas de control.

2.- Con relación a la declaración del servidor Alexander Almendrales, aseguró el apelante que debieron tenerse como probados los siguientes aspectos:

2.1.- Que según el testigo para el año de 2012, en el área de coactivos, el acto de desembargo podía estar firmado únicamente por el funcionario a cargo del expediente.

2.2.- Que solamente con posterioridad al mes de mayo de 2012, se hizo exigible la firma, tanto del funcionario a cargo del proceso, como el jefe de recaudo y cobranzas, en los actos de levantamiento de embargos.

2.3.- Que la alta carga laboral del área de gestión de recaudo y cobranzas, genera dificultades de orden administrativo.

3.- En lo atinente a la declaración de la Jefe de Recaudo y Cobranzas Flor Maritza Corredor Moreno, consideró el impugnante que no se valoraron en favor de su cliente aspectos tales como:

3.1.- el apoyo que sobre redacción y dudas en la actuación, que, según la testigo, se brindan mutuamente los servidores de la dependencia, independientemente de la responsabilidad que, en la sustanciación del proceso, le asiste únicamente al dueño del proceso, quien profiere los actos respectivos.

3.2.- La animadversión de la testigo hacia el acusado, fundada en la desconfianza que le tenía a dicho funcionario, mostrándolo como responsable del hecho investigado.

3.3.- Que la declarante mintió al afirmar que el procesado no cumplió con los requisitos para la expedición de un acto administrativo, si se tiene en cuenta que el procedimiento de la doble firma sólo se implementó con posterioridad al mes de mayo de 2012.

B) En un segundo acápite titulado como “FUNDAMENTO DE DERECHO”, afirmó el recurrente que el funcionario de instancia no tuvo en cuenta las reglas de valoración probatoria, previstas en el C. de P. P. (Ley 600 de 2000), al darle un grado de credibilidad y convicción a las declaraciones de las servidoras (XXX), las cuales, según su dicho, son simples testigos indirectas o de oídas, frente a los hechos objeto de investigación.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2012-199.

- C) Refiriéndose al fallo de primera instancia, aseveró el impugnante, en un tercer acápite, nuevamente titulado como "FUNDAMENTO FÁCTICO", que dicha decisión "...desconoció de hecho e incurrió en suposición probatoria y de valoración...". Como complemento y sustento de su afirmación, reiteró el autor del recurso uno de sus argumentos defensivos, planteados al momento de presentar alegatos de conclusión, en el sentido de solicitar la absolución de su cliente, por considerar que no existe certeza sobre la responsabilidad del acusado, y no se encuentra probado el dolo como elemento subjetivo, estructurante de la falta objeto de sanción. Enfáticamente, adujo el apelante que los elementos subjetivos de la falta, referentes al conocimiento, el querer o la voluntad del actuar de su cliente, no se encuentran soportados en ningún medio probatorio, de aquellos previstos en el artículo 130 del C. D. U. Insistió igualmente el recurrente que su defendido, al firmar la resolución de desembargo, actuó sin conocimiento y voluntad, incurriendo en un posible error de hecho, no inducido, sino consecuencia de la excesiva carga laboral y el desorden administrativo que fueron probados por los testigos de descargos. Agregó que al no haberse valorado dichos aspectos en favor de su cliente, el fallo apelado desconoce el debido proceso, plasmado en el artículo 29 de la Constitución Política, relacionado con el cumplimiento de los principios de presunción de inocencia, presunción de buena fe e in dubio pro disciplinado, los cuales reclama en favor de su prohijado.
- D) En un último acápite, el profesional encargado de la defensa técnica realizó una crítica contundente con relación al juicio de dosificación de la sanción, presentado por el fallador de instancia. Al respecto, expresó que la conducta del disciplinado no generó un daño social y reiteró que no se probó dentro del proceso el conocimiento de la ilicitud, a cargo del sancionado, razón por la cual solicitó a este despacho reestructurar la sanción, imponiendo en término mínimo de inhabilidad de diez años.
- E) Como petición final, el autor de la alzada requiere la revocatoria del fallo, para que en su lugar se absuelva a su defendido.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Antes de dar inicio a estas consideraciones, es importante recordar al impugnante que de conformidad con la previsión legal consagrada en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, "...El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. ...".

Problema Jurídico: Considera el despacho que el tema central que permitirá resolver jurídicamente la alzada, se enmarca en determinar si todo el acervo probatorio, valorado en su conjunto, permite realizar un juicio de adecuación del comportamiento desplegado por el procesado, dentro de la falta objeto de sanción, tal como lo estructuró el fallador a quo. O si por el contrario, según lo pretende argumentar la defensa, nos encontramos ante una insuficiencia o carencia de pruebas, frente a la demostración con certeza del dolo, como elemento integrante de la culpabilidad, complementario de la estructura de la falta disciplinaria. Situación ésta que, en principio, obligaría a acudir al principio procesal del in dubio pro disciplinado, absolviendo necesariamente al procesado, ante la imposibilidad de superar alguna duda probatoria, en este estadio procesal.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2012-199.

Con esta orientación, veamos cuáles fueron los argumentos y análisis probatorios que condujeron al juzgador disciplinario de instancia a considerar cumplido el requisito mínimo probatorio, indispensable para proferir un fallo sancionatorio.

En el acápite correspondiente, inició el fallador señalando que, "... la conducta imputada a (XXX) es netamente dolosa, atendiendo a la forma en la cual se exteriorizó el comportamiento. ...". Esta afirmación es cierta, si se tiene en cuenta que la conformación del punible de prevaricato exige la presencia de un elemento o ingrediente esencial, como es la conciencia de la ilicitud en el agente.

Continuando con la motivación, adujo el funcionario de primer grado que: "...La posibilidad culposa se desdibuja ante la flagrante ilegalidad de la orden de desembargo, la cual no solo era improcedente sino que el disciplinado no estaba asignado para el proceso de jurisdicción coactiva en concreto. ...". Compartiendo la argumentación del a quo, debe aclarar el despacho que la ilegalidad de la decisión apunta a conformar el objeto material del tipo de prevaricato, esa condición, por si sola, no conforma o corrobora el tema de la culpabilidad.

Veamos ahora cuáles fueron las consideraciones efectuadas dentro del fallo apelado, frente a los aspectos cognitivo y volitivo del dolo. Al respecto, expresó el funcionario de instancia:

"...El elemento cognitivo se estructura en cuatro cimientos: 1. El señor (XXX), para la época de la conducta, estaba ubicado en la División de Recaudo y Cobranzas de la Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal. Esto significa que el funcionario conocía el procedimiento de cobro y cuando era procedente el levantamiento de una medida cautelar. Así las cosas, el funcionario conocía que al momento de ordenar el desembargo a favor de la señora (XXX), estaba profiriendo una decisión abiertamente ilegal. ...2. El conocimiento de la ilicitud se ve plasmado también en que el señor (XXX) tiene la profesión de abogado y cuenta con estudios de especialización en Gestión tributaria y aduanera. Así las cosas, gracias a su formación académica identificó sin mayor esfuerzo que la orden de desembargo que había librado era abiertamente ilegal. 3. El investigado profirió una decisión ostensiblemente contraria a la Ley sin que sobrevinieran circunstancias subjetivas que afectaran su libre disposición. Es decir, nadie lo indujo a error y tampoco sobrevinieron circunstancias llamadas a confundir el conocimiento pleno de la ilicitud y del propio comportamiento del agente. ...En lo que respecta al aspecto volitivo, a pesar de que el disciplinado conocía la ilicitud de su comportamiento, dirigió libremente su actuación para alcanzar un propósito (levantamiento de una medida cautelar) sin que su voluntad se haya visto afectada, menguada o inducida en error. ...". (Cursiva fuera de texto).

Con el fin de complementar el tema en que se desarrolla el presente debate jurídico, recordemos cuál ha sido la posición contraria argüida por los sujetos procesales, en ejercicio del derecho de defensa.

El funcionario acusado, en un primer momento, desconoció haber firmado los documentos con los cuales se materializó el punible, es claro que su posición defensiva no estaba llamada a prosperar, ante la oportuna y procedente demostración grafológica. Continuando con su ejercicio de defensa material, desde su versión inicial, el servidor implicado empezó a esbozar su estrategia defensiva, en la cual expresó al despacho instructor de conocimiento tener en cuenta las cargas de trabajo, posiblemente excesivas, como la razón que lo llevó a firmar, involuntariamente, los documentos tantas veces mencionados. Ya en el instante de los descargos y las alegaciones, presentados en el transcurso de la audiencia, la tesis defensiva varió considerablemente, al expresar que la actuación del procesado, en el evento de probarse, pudo haber sido el resultado de un error involuntario, al firmar la documentación, sin el conocimiento y voluntad que se predicen del dolo. Lo anterior con el fin de justificar o exculpar la conducta objeto de reproche, con la ya citada carga excesiva de trabajo.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2012-199.

Para tomar una posición conclusiva que nos permita inclinar la balanza en favor de alguna de las dos tesis planteadas, ya sea la del a quo o la de la defensa, es necesario no apartarnos en ningún momento de la estructura concreta de la falta disciplinaria por la que fue citado a audiencia el disciplinado, siendo sobre dicho comportamiento abstracto que deberá establecerse el posible cumplimiento del requisito probatorio mínimo establecido para sancionar, en el texto del artículo 142 del C. D. U.

En este orden de ideas, se llamó a responder al procesado por realizar objetivamente la descripción típica consagrada en el artículo 413 del Código Penal (Ley 599 de 2.000), definida como el punible de prevaricato por acción.

Para efectos de dimensionar en qué consiste la realización objetiva del tipo penal de prevaricato, como complemento de la falta disciplinaria que motivó esta actuación, veamos si aparecen cumplidos los elementos estructurales del punible en cuestión.

La descripción penal empieza por exigir un sujeto activo cualificado, referido a un servidor público con capacidad funcional de proferir, cualquiera de los tres actos que conforman el objeto material del ilícito, - resolución dictamen o concepto -.

Efectivamente, tal como lo hizo ver el funcionario de primer grado, esta condición especial del disciplinado aparece probada con el aporte documental de la hoja de vida, en el cual se pudo comprobar su vinculación a la DIAN como servidor de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, desde el año 2010. Igualmente se definieron allí su cargo, experiencia y funciones asignadas como Gestor 1 Nivel 301, Grado 01, el cual desempeñaba durante la fecha en que se desarrollaron los hechos.

En un segundo elemento, debemos considerar la conducta objeto de reproche, enmarcada en el verbo rector PROFERIR, que en su sentido gramatical y aplicado al caso sub examine, hace referencia al hecho de haber expedido o pronunciado el funcionario acusado una decisión, a través de la cual ordenó el desembargo irregular de las cuentas bancarias pertenecientes a la contribuyente Julia Mercedes Gómez Salcedo, identificada con el Nit N°23552.355. La anterior decisión administrativa, plasmada o contenida en la resolución N°201202.31000154 del 14 de mayo de 2012 y el comunicado de la misma fecha, dirigido al Banco Agrario, ambos instrumentos o documentos, suscritos por el servidor acusado.

En armonía con la valoración probatoria realizada por el fallador a quo, es innegable que las pruebas documentales, testimoniales, de inspección y periciales, allegadas al plenario, demuestran con certeza que la conducta aludida existió, pero por sobre todo que la misma fue ejecutada por el servidor disciplinado, en una efectiva ejecución irregular de sus deberes funcionales.

Nótese que en un eficaz desarrollo probatorio, el comportamiento objeto de reproche fue puesto en conocimiento de del operador disciplinario, a través de sendos informes, signados por las servidoras públicas, (XXX), la primera como Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal y la segunda como Jefe de la División de Gestión de Recaudación y Cobranzas de la misma dependencia. Ambas servidoras públicas, actuando como superiores inmediatas del encartado y en cumplimiento del deber legal que las obligaba a dar traslado de los hechos por ella conocidos, al competente disciplinario, relataron las pesquisas primigenias que debieron realizar al tener conocimiento del de los hechos que denotaban el desembargo ilegal de una contribuyente. Es con base en estos informes de servidoras públicas, en ejercicio de sus funciones, que la conducta objeto de este juicio empezó a tomar cuerpo, al establecerse los medios documentales en que se transfirió o materializó la supuesta orden emitida por la administración, a través de uno de sus

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2012-199.

agentes, con destino al Banco Agrario. Surge igualmente en estas pruebas documentales la primera imputación en contra del servidor acusado, al ser sus jefes quienes refieren que la resolución y el comunicado contentivo de la decisión ilegal, aparece presuntamente firmados por el procesado Pulido Chacón.

Con el fin de dar mayor solidez a los anteriores informes de servidor público, las signatarias de los documentos fueron escuchadas en declaraciones juramentadas, antes y durante la audiencia, ratificando en todo momento sus relatos, sin que pudieran evidenciarse inconsistencias en sus dichos, que pudieren alterar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se llevó a cabo el comportamiento aquí reprochado.

En una decisión acertada, orientada a cerrar cualquier posibilidad de duda frente a la autoría del comportamiento sometido a juicio, el instructor disciplinario, desde el comienzo de la actuación, sometió la Resolución de desembargo 201202310000154 del 14 de mayo de 2012, junto con el comunicado de desembargo 2012023200000154 de la misma fecha, al Instituto de Medicina Legal, con el fin de obtener el correspondiente cotejo grafológico, tendiente a establecer si las firmas estampadas en dichos documentos fueron suscritas por el procesado. Agotado el trámite de peritación pertinente, se obtuvo el dictamen grafológico No. 281889 del 17 de diciembre de 2012, aclarado a petición del acusado con el dictamen 289317 del 1 de abril de 2013. En forma coincidente los dos dictámenes anunciados concluyeron que existe identidad gráfica entre las firmas dubitadas, contenidas en los documentos remitidos para la prueba, y las firmas consignadas en las muestras patrón de Luis Eduardo Pulido Chacón, aportadas para el estudio.

Con las anteriores pruebas periciales, sin lugar a dudas aparece probado en el proceso el objeto material del punible de prevaricato, sobre el cual recae o se patentiza la conducta del sujeto agente.

Pasemos ahora a evaluar la demostración del ingrediente normativo que complementa el tipo penal de prevaricato, esto es el proferimiento de una resolución, para el caso que nos convoca, manifiestamente contraria a la ley. Con relación a este tópico las razones del fallador de instancia siguen mostrándose valederas para este despacho ad quem. Sin lugar a dudas, el procesado no tenía ninguna posibilidad legal que lo facultara para proferir la decisión de desembargo, tal como efectivamente lo hizo. Inicialmente, debe partirse del hecho que el expediente de cobro coactivo no le había sido asignado para su correspondiente sustanciación. Adicionalmente, la ilegalidad resultó manifiesta, pues contrariando abiertamente la normatividad tributaria, pudo probarse que para la fecha de los hechos la contribuyente tenía obligaciones pendientes por valor de \$ 5'268.100, oo, situación que riñe con la manifestación realizada por el acusado, quien motivó la resolución de desembargo, afirmando como causal el pago de las acreencias perseguidas a la destinataria de la acción de cobro. El elemento normativo del prevaricato, aquí referido, aparece soportado en las diligencias de inspección administrativa realizadas y en los documentos que conformaron el objeto material del tipo. Adicionalmente, las pruebas testimoniales de descargos, corroboraron el hecho, pues en forma conteste relataron que, al advertirse la irregularidad del desembargo, se confirmó inmediatamente la improcedencia de esa decisión.

Las consideraciones hasta el momento realizadas, son suficientes para afirmar, avalando íntegramente la decisión apelada, que los medios probatorios allegados al proceso, demuestran con certeza la realización objetiva del punible de prevaricato, complementando la estructura de la falta disciplinaria definida en la acusación. Así lo demuestra el análisis probatorio realizado por el funcionario de primer grado, y lo corrobora esta instancia disciplinaria, al hacer su propio análisis o valoración de las pruebas, según lo expresado en anteriores párrafos.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2012-199.

Con relación al dolo en el proceso de demostración objetiva del tipo penal de prevaricato, nos permitimos transcribir algunos apartes jurisprudenciales, que únicamente complementan esta fundamentación:

“...Prevaricato. En tratándose de la prevaricación, que solo es punible en cuanto concurra el dolo, éste requiere entendimiento de la manifiesta ilegalidad de la resolución proferida, conciencia de que con tal proveído se vulnera sin derechos el bien jurídico de la recta y equilibrada definición del conflicto que estaba sometido al conocimiento del servidor público, quien podía y debía dictar un pronunciamiento ceñido a la Ley y a la justicia... (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M. P. : Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote, Sentencia: Mayo 15 de 2000, Referencia: Expediente 13601). ...”.

“...Prevaricato. En este delito el dolo se traduce en el conocimiento que debe tener el servidor público de la manifiesta ilegalidad de la decisión proferida, conciencia de que con tal determinación se vulnera sin derecho el bien jurídico de la recta y equilibrada definición del asunto, y sin que sea menester demostrar el móvil que guio la acción del funcionario. Bien puede suceder que éste se establezca, y pase a ser elemento útil en la determinación de la culpabilidad dolosa, pero ello no quiere decir que una particular finalidad delictiva sea parte integrante del dolo. En la medida en que el prevaricato por acción requiere para su realización el conocimiento por parte del funcionario de la manifiesta ilegalidad de la resolución proferida, es claro que basta el simple comportamiento del agente, independientemente de sus consecuencias, para que se tenga por punible. Y si no exige un determinado resultado, el dolo eventual deviene incompatible con la naturaleza de este ilícito, pues lo contrario sería pretender que en todo proferimiento de una decisión fuera implícito el riesgo de que resulte contraria a derecho y que si tal posibilidad se aceptare, se estuviere ante un dolo eventual. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M. P.: Dr. Fernando Arboleda Ripoll Sentencia: Abril 4 de 2.002 Referencia: Expediente 17008). ...”.

Con estos lineamientos jurisprudenciales que complementan y aclaran la decisión del aquo, es innegable que el conocimiento, la conciencia o entendimiento del actuar reprochado al procesado, se evidencian en su amplia experiencia y formación profesional, situaciones documentalmente probadas con el extracto de su hoja de vida. Ciertamente, al ser el acusado un abogado especialista en gestión tributaria, reconocido, según la prueba testimonial, como el funcionario que realizaba labores de inducción y asesoramiento al interior de la división de recaudo y cobranzas, el conocimiento de la ilicitud de su actuar es inminente, pues precisamente con ocasión a esas características personales de experiencia y formación profesional y laboral, resulta imposible pretender que el procesado no conociera y comprendiera el trámite y los requisitos procesales necesarios establecidos para tomar una decisión de desembargo. Es claro que un funcionario con las características ya señaladas, al encargarse de la sustanciación de una decisión de levantamiento de una medida de embargo, como mínimo, debe empezar por establecer si el expediente respectivo le fue asignado o repartido, para su desempeño funcional. Acto seguido deberá proceder al estudio detallado de la situación fáctica precisa y de los requisitos de procedibilidad legal de la decisión, acorde con los medios probatorios a su alcance. Son estas las razones que llevaron al a quo a considerar probado el conocimiento del dolo, pues efectivamente el servidor procesado, para proferir la determinación en comento, debió ubicar, en primer lugar, el caso o expediente, constatando que no estaba bajo su resorte funcional, sino que por el contrario le correspondía a su compañero de labores, el funcionario Alexander Almendrales Llanes, único titular de la sustanciación y conocimiento de la actuación. Pese a lo anterior, un servidor como el aquí procesado, poseedor de tanta experiencia, como sus mismos compañeros de labores lo afirmaron, decidió obviar las situaciones anteriormente señaladas, y asumió la decisión de proferir el desembargo, de manera personal, sin que mediaran los requisitos de procedibilidad; sin someter el asunto a los procedimientos establecidos en el Sistema SIPAC; sin

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2012-199.

someter el caso a la revisión y aprobación de la Jefe de la División; sin tramitar la comunicación de desembargo, a través de los medios documentales de la dependencia. Tantas inconsistencias o irregularidades en el desarrollo del quehacer funcional del servidor investigado, visualizadas dentro del caudal probatorio allegado, conforman los momentos cognitivos y volitivos del dolo, predicables en el comportamiento del investigado, en grado de certeza.

El principio general de imputación subjetiva en materia disciplinaria señala que *"En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa"* (Artículo 13, ley 734 de 2002).

Acudiendo dentro del marco autorizado de integración normativa por el artículo 21 del Código Disciplinario Único, al artículo 22 del Código Penal define que la conducta es dolosa cuando *"... el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. ..."*

Con relación al dolo ha sostenido reiteradamente la doctrina disciplinaria: *"...Entonces, para que exista dolo basta que la persona haya tenido conocimiento de la situación típica aprehendida en el deber que sustancialmente se ha infringido, y haya aceptado que le corresponde actuar conforme al deber. El conocer ya involucra al querer, pues si conozco y realizo la conducta es porque quiero, lo cual ha sido pregonado por HRUSCHKA al sentenciar que "quien sabe lo que hace y lo hace, quiere hacerlo..."* (Dogmática del Derecho Disciplinario, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, edición 2ª, pag. 340) ...".

Bajo este concepto debemos concluir que la falta objeto de acusación en el presente fallo, se entiende cometida por el procesado a título de DOLO.

Finalmente, en lo que atañe al juicio de dosificación de la pena realizado por el a quo, este despacho considera que los tres aspectos que fueron tenidos en cuenta por el fallador, como atenuantes de punibilidad, en favor del sancionado, no permiten aplicar la pena partiendo del mínimo posible de diez años. Contrario a lo manifestado por el apelante, deben considerarse acertados los razonamientos frente al daño social, pues efectivamente, comportamientos de origen delictual, que atentan contra la Administración Pública, desdibujan la imagen y credibilidad de una entidad como la Dian, encargada de cumplir una misión esencial en la organización y funcionamiento del Estado, como lo es la garantía de la seguridad fiscal y el orden económico.

Basten las anteriores consideraciones para ordenar, tal como se hará en la parte resolutive de la presente decisión, que este despacho Ad quem Confirma en su totalidad el fallo apelado, despachando negativamente las razones del defensor impugnante.

En tal virtud, la Directora General de la UAE Agencia del Inspector general de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

PRIMERO. RECHAZAR los argumentos y peticiones de impugnación presentados por el abogado defensor (XXX), de acuerdo a las motivaciones expuestas en precedencia.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2012-199.

SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior determinación **CONFIRMAR** en su totalidad el fallo proferido por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la UAE Agencia ITRC, en sesión de audiencia especial realizada el 24 de junio del año en curso, a través del cual se declaró la responsabilidad disciplinaria del servidor (XXX), de condiciones civiles y personales conocidas en autos, imponiéndosele como sanción Destitución e Inhabilidad General por el término de trece años, al considerarlo autor responsable de la falta disciplinaria cometida en hechos y circunstancias aquí señalados, de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO. NOTIFICAR el contenido de esta decisión a los sujetos procesales, de conformidad con las previsiones legales contenidas en los artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO. A través de la Secretaría Técnica de esta UAE, **LIBRENS** e citaciones al disciplinado, a la dependencia donde actualmente labora en la DIAN o a la última dirección registrada en su hoja de vida, dentro del proceso disciplinario. Al defensor de confianza apelante se le citará a la última dirección procesal registrada dentro del expediente. En los oficios respectivos, se les informará a los sujetos procesales, que una vez vencido el término de ocho (8) días a partir del envío de la citación, su no comparecencia, dará lugar a la fijación de un edicto, por el término de tres (3) días, para notificar esta decisión de segundo grado.

QUINTO. La presente decisión queda en firme el día de su suscripción, pero sus efectos jurídicos se surten a partir de la notificación, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.

SEXTO. Una vez surtida la notificación del presente fallo, **REGISTRAR** La sanción disciplinaria ante la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, según lo ordena el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 48, numeral 57 de la misma norma. Igualmente REMITIR copia de la presente decisión al nominador del sancionado, para que proceda, en a ejecutar la sanción impuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º y PARÁGRAFO del artículo 172 del C. D. U.

SÉPTIMO. Ejecutoriada materialmente esta decisión y libradas las comunicaciones de ley, DEVOLVER la actuación al despacho de origen, para dar cumplimiento al presente fallo y Archivar físicamente el expediente.

OCTAVO. Contra el presente fallo no procede recurso alguno.

CÓPIESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
Directora General

Proyectó: Demetrio Augusto Parra Jiménez
Revisó, corrigió y aprobó: Carmen Maritza González M. – Directora General.